

1500566-23.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500566-23.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500566-23.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056454/2022 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 23291235 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2056454 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUMBERTO ALVES SOUZA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

HUMBERTO ALVES SOUZA e KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. Art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, porque, consoante documento inicial acusatório, por volta das 11h40min do dia 26 de fevereiro de 2022, nas dependências da Penitenciária II, situada na Rodovia 354, km 44,5, nesta cidade comarca de Franco da Rocha/SP, HUMBERTO ALVES SOUZA induziu sua namorada, KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA, a trazer consigo, , para fins de tráfico, as

seguintes drogas: a) 01 porção de maconha, pesando, aproximadamente, 160g de massa bruta; b) 02 invólucros de papel, pesando, aproximadamente 130g, contendo a substância conhecida como K4 e c) 03 comprimidos de ecstasy, pesando, aproximadamente, 20g; substâncias causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 11h40min, nas dependências da Penitenciária - II, situada na Rodovia 354, Km 44,5, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA, qualificada a fls.20, trazia consigo, para fins de tráfico, as seguintes drogas: a) 01 porção de maconha, pesando, aproximadamente, 160g de massa bruta; b) 02 invólucros de papel, pesando, aproximadamente 130g, contendo a substância conhecida como K4 e c) 03 comprimidos de ecstasy, pesando, aproximadamente, 20g; substâncias causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 04/03/2022 (fls. 130), foi o réu Humberto citado (fls. 175) e a ré Kayllaine por sua vez, deu-se por citada tendo constituído defensor nos autos (fls. 251/254) . Os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 181).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e os réus foram interrogados ao final da instrução.

Alegações finais apresentadas em audiência.

É o relatório.

Passo a decidir.

Rejeito a preliminar de nulidade por revista vexatória.

O relato das testemunhas e da acusada foi uníssono no sentido de que, após o scanner, a acusada foi encaminhada para uma sala reservada e, em tal local, ela teve de retirar a blusa e top que vestia por estarem com os entorpecentes nele presos. Estava sozinha no local com outra agente do sexo feminino tendo sido-lhe entregue outra roupa. em seguida, sem qualquer situação violadora de sua dignidade pessoal. Ainda, foi-lhe solicitada a retirada da camisa foi porque as drogas estavam nela fixados.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), do auto de exibição de apreensão (fls. 07), laudo de constatação (fls. 10/14) e laudos periciais definitivos (fls. 331/333 e 334/335), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvida perante a autoridade policial, a ré Kayllaine Magalhães Nogueira disse que na última segunda-feira, HUMBERTO realizou ligação telefônica para o celular da declarante (11-7870.XXX) e disse que chegariam algumas coisas na casa da declarante e o pediu para que as levasse para o presídio, a pretexto de visitá-lo. Na última sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, a declarante chegou do trabalho e, por volta das 22:30 horas, foi chamada em casa por um motoboy, o qual disse que teria uma entrega para a declarante. Ele estava vestido como "um entregador normal", então entregou um envelope para a declarante, sem nada mais dizer. Nesta manhã, a declarante apanhou um "Uber" até Franco da Rocha, sendo que antes escondeu as drogas recebidas do motoboy no top que trajava. Permaneceu na fila e seguia para visitar HUMBERTO, quando foi flagrada por agentes penitenciários quando submetida ao aparelho de scan corporal, ocasião em que suspeitaram da silhueta da declarante,

até que uma das agentes a revistou e constatou as drogas escondidas em suas vestes. Sabe que entre as drogas havia maconha e "doce". HUMBERTO não prometeu nenhum valor pela entrega, de forma que a declarante concordou em fazer a remessa das drogas "pra ajudar ele". A declarante, na presença de seu advogado, informa que deseja confessar ampla e espontaneamente os fatos, bem como que tem interesse em eventual acordo de não persecução penal que o Ministério Público possa celebrar, caso seja esse o entendimento do Nobre Promotor de Justiça responsável pelo caso. Acrescenta que durante o exame de scan acabou tomando conhecimento de que está grávida. Acredita que de fato esteja grávida, porque sente dores abdominais. Perguntada pelo Nobre causídico, a declarante esclarece que as drogas estavam todas escondidas em seu top, colocadas em seu corpo, e que a agente penitenciária acabou estranhando o suposto feto na barriga da declarante, de forma que a droga, na verdade, foi encontrada por acaso. Está muito arrependida, nunca passou por situação semelhante, está envergonhada diante da presença de sua mãe nesta delegacia e nunca mais pretende se envolver em fatos delituosos.

Em juízo, afirmou que os fatos são verdadeiros. Disse que o réu lhe ligou dizendo que estava correndo risco de vida e que iriam chegar algumas coisas na sua casa. Imaginou que seriam drogas. Um motoboy chegou na sua casa com as roupas tendo os objetos já colocados na roupa. Ele disse que era para entrar com os objetos. Perguntou os fatos a Humberto mas ele não explicou o que era. Havia um uber que a levou para sua a penitenciária. Na penitenciária, foi encontrado o entorpecente e os entregou para as agentes. Não teve mais contato com Humberto. Não teve mais nenhum contato com Humberto. Tinha relacionamento amoroso com o réu. Não sabe por qual crime o réu estava preso. O réu Humberto faz uso de entorpecente mas não sabe qual droga. Trabalha como recepcionista e tem um filho recém nascido. Acreditou que estava correndo risco por saberem de seu endereço, mas não recebeu nenhuma ameaça. Foi pedido que a depoente ficasse nua na revista, estando sozinha com a agente nesse momento. Foi-lhe entregue outra roupa na ocasião.

Por sua vez, o réu Humberto Alves Souza, na fase inquisitorial, esclarece que cumpria pena em Osasco/SP, mas foi transferido para Franco da Rocha/SP, no Pavilhão 2, onde estão a maioria dos detentos primários. Em determinada ocasião, acabou se atrasando para se recolher à cela, motivo pelo qual foi determinada sua transferência para o Raio 3, local destinado aos detentos de maior periculosidade. Nesse local, acabou sendo influenciado a utilizar drogas comumente comercializadas no presídio, tais como K4 e 'doce' (ecstasy), ambas de alto poder viciante. Esclarece que cada microponto de K4 custa R\$ 40,00 (quarenta reais) no sistema, de forma que uma folha tamanho padrão A4 chega a valer R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em média. Um microponto de ecstasy valia entre R\$ 30,00 (trinta reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais). O declarante acabou se viciando, pegou diversos micropontos dessas drogas e entrou em uma dívida de cerca de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). O declarante passou a ser cobrado de forma incisiva pelos detentos aos quais devia, os quais disseram que deveria resolver a dívida caso contrário sofreria as consequências. Seus parentes mais próximos são todos pessoas simples e trabalhadoras e não conseguiam contribuir com mais do que R\$ 200,00 (duzentos reais) ao mês, quantia essa que não foi aceita pelos traficantes, que queriam uma solução rápida para a dívida. Tentou realizar faxinas para os seus companheiros, além de outros afazeres, mas a dívida era muito alta diante de sua capacidade financeira. Como não conseguiu nenhuma solução, os traficantes disseram que o declarante teria que se virar e conseguir com os seus parentes alguém para trazer as drogas deles da rua para o presídio, como forma de saldar o débito. Eles conseguiram um aparelho celular, então o declarante ligou para a sua companheira KAYLLAINE, e disse a ela que precisava que ela entrasse com a droga no presídio. KAYLLAINE se negou e resistiu muito, mas o declarante a pressionou bastante e disse que poderia morrer, então ela acabou cedendo e aceitou participar do esquema para salvar a vida do declarante. KAYLLAINE não iria ganhar nada por essa empreitada. O declarante não pode mencionar o nome das pessoas que o coagiram a traficar as drogas devidos à conhecida Lei do Silêncio que impera no mundo do crime. O

declarante ligou para KAYLLAINE e informou que ela receberia algumas coisas, as quais deveria entrar no presídio e entregar para o declarante a pretexto de visitá-lo. O declarante está muito arrependido por ter envolvido sua companheira nesse crime, mas estava desesperado, está sendo ameaçado por traficantes e também passa por problemas de saúde, porque foi baleado por diversas vezes e seu organismo está rejeitando algumas próteses que recebeu e no sistema penitenciário não está conseguindo os cuidados necessários, de forma que gostaria de passar por uma avaliação médica e receber um tratamento digno. Gostaria de apelar para que fosse transferido de unidade prisional porque risco de ser morto.

Em juízo, o réu alegou que os fatos são verdadeiros. Em novembro de 2021, foi transferido para outro pavilhão e passou a usar entorpecentes e estava devendo R\$28.000,00. Passou a sofrer ameaças. Pediu para a Kaylane, em 11/03 para que arrumasse R\$28.000,00. Ela disse que iria ver se arrumava. Eles pediram que ligasse para ela e Kaylane disse que não tinha conseguido o dinheiro que tinha pedido para agiota, inclusive, sem sucesso. Foi agredido. Passados cerca de três dias ligou novamente para Kaylane e disse que era tinha que trazer entorpecentes para o interior do presídio. Disse para Kaylane que ela teria que trazer folhas de entorpecentes. Disse a ela que era entorpecentes. Não teve mais contato com a ré. Foi transferido para outro presídio no dia que foi preso.

A versão dos acusados guarda parcial amparo na prova dos autos.

A testemunha Daniel Barbosa Garcia, agente penitenciário, na Delegacia de Polícia, disse que é agente penitenciário, e atualmente exerce suas funções na Penitenciária Nilton Silva, conhecida como P2 de Franco da Rocha. Nesta data, foi destacado para auxiliar no procedimento de revista, já que sábado é dia em que os detentos recebem visitas. Estava operando junto ao aparelho de scan corporal, quando notou que a visitante KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA trazia algo junto ao seu corpo, o que foi possível observar pela imagem do aparelho. Como procedimento, comunicou tal situação para sua superior hierárquica, Luciana, que então indagou de KAYLLANE, tendo ela admitido que estava em poder de drogas, as quais seriam entregues a seu companheiro, o detento HUMBERTO ALVES SOUZA. KAYLLANE entregou diversas drogas que trazia escondidas em sua roupa, então foi conduzida até a delegacia de Mairiporã, onde funciona o plantão de Franco da Rocha atualmente. O depoente presenciou o momento em que o delegado de plantão entrevistou KAYLLANE, tendo ela afirmado que foi contatada por telefone por HUMBERTO ALVES SOUZA, que disse a ela que mandaria drogas em sua residência para que então promovesse a remessa do entorpecente para o interior do presídio, a pretexto de visitá-lo. KAYLLANE tentou ingressar no presídio com, segundo ela afirmou, "doce" (que seria ecstasy), maconha e M4 (espécie de maconha sintética).

Em juízo, disse que estava operando o aparelho de scanner na ocasião tendo a ré passado na revista. Percebeu alteração na imagem, tendo pedido que ela passasse novamente. A alteração persistiu e ela foi encaminhada para sua colega que estava na revista na portaria. Não acompanhou o momento em que o entorpecente foi encontrado. Quando perguntado, Kaylane disse que trazia algo ilícito mas não especificou. Ela entregou esse objeto para a diretora de portaria, tendo encontrado pacotes que aparentavam ser entorpecentes. Não acompanhou o depoimento da ré na delegacia. Recorda-se de ter assinado o depoimento na delegacia. A ré admitiu que o preso Humberto pediu que ela trouxesse entorpecentes, mas não se recorda do meio que ele usou para lhe pedir isso. A ré disse que estava levando "doce". Não teve contato com o réu Humberto no dia dos fatos e nem conversou com ele. Prestou depoimento no procedimento administrativo da penitenciária. Os entorpecentes estavam na roupa da presa na parte superior do corpo e na cintura que foi entregue pela visitante para a outra agente.

No mesmo sentido foram as declarações da segunda testemunha, Gislene Maria Loriani Sachs na Delegacia de Polícia, o qual disse que também é agente penitenciária e

participou da mesma diligência narrada por seu companheiro. Durante procedimento de revista, a visitante KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA foi surpreendida trazendo diversos tipos de drogas escondidas em suas vestes, sendo que na ocasião declarou que iria entregá-las a seu companheiro, o detento HUMBERTO ALVES SOUZA, a pedido dele mesmo. KAYLLANE admitiu os fatos na presença do delegado.

Em juízo, a testemunha disse que foi encontrado entorpecente nas vestes da ré, mas não se recorda se ela confessou os fatos. Não se lembra de Kayllane ter dito que as drogas foram levadas a pedido de outro preso.

Quanto aos agentes de segurança ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar os réus de forma leviana e gratuitamente.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido."(JTJ 208/273).""Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo."(TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram precisos o suficiente a indicar que a condenação é a medida que se impõe. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos agentes ouvidos, levam à certeza de que a acusada guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação.

Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa à ré Kayllane a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ainda, há de se mencionar que o fato de ser o réu Humberto usuário ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito. O fato de Kayllane entregar entorpecentes a terceiros já configura o crime em questão, sendo irrelevante se venderia ou não.

A alegação de que o fato criminoso teria sido cometido sob grave ameaça de terceiros não afasta a culpabilidade eis que não há prova concreta das ameaças sofridas já que o teor das ameaças sofridas se mostrou vago e carente de lastro probatório. A versão apresentada pelos acusados é conflitante. Humberto disse que contou para Kayllane quanto às ameaças sofridas em visitas e chegou a lhe pedir que conseguisse a quantia de R\$28.000,00 para quitação. Afirmou ainda que ela tentou obter os valores com agiota, sem sucesso. A corré, no entanto, apresentou relato distinto sobre as supostas ameaças. Disse que ele apenas lhe informou esse fato por telefone, não explicou qual seria o problema que estaria sofrendo e sequer mencionou estar devendo quantia. Destaco ainda, que os réus deveriam ter procurado a autoridade policial competente informando as ameaças sofridas, buscando meios de

verem-se protegidos, o que afasta a indicação de que seria inexigível conduta diversa. De se notar ainda que, mesmo tendo sido frustrada a tentativa de ingresso da droga no presídio, não houve qualquer agressão ou violência sofrida pelos réus. O valor da suposta dívida, apesar de elevado, era possível que buscasse outros meios de quitação, não havendo que se falar, portanto, em inexigibilidade de conduta diversa.

Corriqueiras são as alegações de ameaças em crimes dessa natureza, sendo necessário que esta seja acompanhada de um mínimo de certeza para sua consideração, eis que sequer conseguiram os réus indicar de modo preciso o teor das ameaças sofridas. A mera menção acerca da coação não atesta a sua existência e, muito menos, a sua irresistibilidade, sendo este um ônus probatório da Defesa. Para que haja o reconhecimento da coação moral irresistível, ela deve restar cabalmente demonstrada.

Nesse sentido:

“Quanto à invocada excludente de culpabilidade, não se incumbiu o denunciado de demonstrar, como lhe cabia, que agiu sob coação moral irresistível. Ora, para que possam ser admitidas, as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade devem ficar cabalmente comprovadas, competindo tal ônus ao réu. Por óbvio, não basta apenas alegá-las. Ademais, indispensável à caracterização da dirimente que a coação seja insuperável, invencível, diante de perigo sério e atual, de tal sorte que o coagido não consiga arrostá-la senão pela prática da infração. E tal não decorre, necessariamente, da alegada condição de devedor de traficante.” (STJ, REsp 1711751/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, publicação 14.03.2018)

“Na hipótese vertente, a corré alegou ter agido nos moldes retratados na denúncia, sob o argumento de temor de represálias decorrentes de dívidas contraídas com um traficante. Não basta para se acolher a excludente de culpabilidade a vaga alegação de temor. É necessário a prova de fato concreto, que justificasse a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime. Não se vislumbrando na instrução do processo a ocorrência dessa situação extrema, torna-se inconvincente a tese defensiva.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500388-37.2019.8.26.0558, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1ª Câmara Criminal, j.20/02/2021).

Não há que se falar em atipicidade da conduta por crime impossível ou tentativa, em razão de o tráfico de drogas ter se consumado no instante em que a ré recebeu e trazia consigo os entorpecentes para o consumo alheio (crime de ação múltipla e formal), além de o meio utilizado, levar drogas em partes íntimas para o presídio em dias de visita, ser absolutamente eficaz e conhecido para a prática do delito. Do contrário, não haveria a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisionais, fato conhecido por todos.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. Não houve nenhuma contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no julgado proferido pela Corte de origem, de modo a gerar o pretendido reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo efetivamente externou as razões pelas quais entendeu configurada a apontada nulidade arguida pela defesa (relativa à ordem do interrogatório) e considerou devida a absolvição da acusada.

3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada. 4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes. 5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. 6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio. 7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se, tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes. 10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa. 11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada. 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator" 2 REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018.

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES RECURSO DA ACUSAÇÃO PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PELA APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NÃO ACOLHIMENTO QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA NÃO SE MOSTRA EXACERBADA A PONTO DE IMPEDIR O REDUTOR MÁXIMO A TENTATIVA DE LEVAR DROGAS PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL JÁ FOI CONSIDERADA NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL SUA UTILIZAÇÃO PARA MODULAR O REDUTOR, SOB PENA DE BIS IN IDEM - RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS DOS RÉUS ADILSON E DIEGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL NÃO ACOLHIMENTO CRIME FORMAL - NÃO DEMONSTRADA, ADEMAIS, A INEFICÁCIA

ABSOLUTA DO MEIO UTILIZADO PARA EFETIVAR A INTRODUÇÃO DOS ENTORPECENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CRIME, ADEMAIS, CONSUMADO ANTES MESMO DE TENTAR INTRODUIR A DROGA NO PRESÍDIO PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS CONFISSÃO NÃO POSSIBILITA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO COL. STJ INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS, QUANTO AO RÉU DOUGLAS, QUE ADQUIRIU O ENTORPECENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TJSP; Apelação Criminal 0002143-95.2017.8.26.0638; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021

Sequer há que se falar em desclassificar o crime para o previsto no §2º do art. 33. A ré Kayllaine não induziu o corréu a utilizar entorpecentes, mas apenas atendeu ao pedido deste transportando a droga.

Por fim, o crime se deu no interior de um presídio, conforme relato unânime da prova oral e demais documentos que instruem o feito, devendo incidir a causa de aumento prevista no inc. III, do art. 40, da Lei de Drogas.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Quanto à ré Kayllaine.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que a ré é primária e de bons antecedentes. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico presente a atenuante relativa à confissão espontânea. Não incidem agravantes na espécie. Por ter sido a pena fixada no mínimo, deixo de incidir a atenuante.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos agentes penitenciários, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6, passando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por ser a acusada primária e possuir bons antecedentes, deve ser observado o que prescreve o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, observando (na fixação do quantum dessa redução) o que prescreve o art. 42 da mesma lei, tornando definitiva apenas para o crime de tráfico de drogas, de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica da ré, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime inicial aberto, quanto à ré Kayllaine, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO A pena privativa de liberdade imposta à

acusada por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o art. 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Quanto ao réu Humberto

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal e o art. 42 da lei 11.343/06, entendo que a quantidade de drogas apreendida não foi expressiva, não havendo razão para exasperar a pena. Fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. O réu é portador de maus antecedentes e multirreincidente, com 04 condenações com trânsito em julgado. Dessa forma, utilizo os processos nº 1520250-63.2019.8.26.0050 e 1500485-09.2019.8.26.0050 (fls. 140/141) para elevar a pena base em 1/6 a título de maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência pelos processos nº 1510907-91.2019.8.26.0228 e 1511671-29.2019.8.26.0050. Ainda que tenha confessado o delito, prevalecem as circunstâncias agravantes reincidência. Assim, elevo a pena em 1/8 resultando em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois dias) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos agentes penitenciários, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6, passando para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Entendo não ser aplicável a redução de pena prevista no § 4º do art. 33 ao caso. Insta asseverar, oportunamente, que os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

O réu é possuidor de maus antecedentes e reincidente, não se enquadrando nos requisitos legais para aplicação do redutor.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida no regime inicial fechado, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes, reincidente e pela quantidade da pena aplicada, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno os réus KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA e HUMBERTO ALVES SOUZA, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A) KAYLLAINE MAGALHÃES NOGUEIRA às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa

e quatro) dias-multa, no mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade imposta à acusada por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o art. 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal da ré, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código Penal;

B) HUMBERTO ALVES SOUZA à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

A ré Kayllaine poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução.

Quanto ao Réu Humberto, por ter permanecido preso durante o processo, assim deverá permanecer. Oficie à Penitenciária recomendando-o à prisão. Expeça-se Guia de Recolhimento à VEC competente.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE e Guia à VEC com relação a Ré Kayllaine, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Defiro aos réus a gratuidade de justiça, isentando-os do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Franco da Rocha, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA